

- Expediente nº.: EXP202201212

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN

Examinado el recurso de reposición interpuesto por A.A.A. (en lo sucesivo, la parte recurrente) contra la resolución dictada por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 10 de octubre de 2022, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10/10/2022, se dictó resolución por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente **EXP202201212**, procediéndose al archivo de las actuaciones previas de investigación.

Dicha resolución fue notificada a la parte recurrente en fecha 10/10/2022 según consta en el acuse de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: La parte recurrente ha presentado en fecha 16/10/2022, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición, fundamentándolo básicamente en las alegaciones presentadas con anterioridad; en particular señala lo siguiente:

“(...) No siendo especialista en la materia, interpreto que lo que la agencia está diciendo es Orange es la titular de la línea, la cual estaría siendo subcontratada a Advento Networks, o bien que Orange es el operador de la línea y la titularidad de la misma en España corresponde a Advento Networks. En cualesquiera de los dos supuestos, serían partes interpuestas entre STG Group y el reclamante (yo) y beneficiarias de una actividad comercial más o menos lucrativa con el usuario final (STG Group).

4. El hecho de STG Group tener su sede fuera de la Unión Europea plantea una dificultad al hecho de aclarar la intención real de las llamadas, pero ello no exonera de su cuota de responsabilidad a las otras partes implicadas, las cuales serían responsables civiles subsidiarias.

5. En este sentido es claro el artículo 120.2 y por analogía el 120.4 del Código Penal: «Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente [...] 2) Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 212. [...] 4) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios [...]»

(...)

7. De este modo, considero que el silencio de STG Group es irrelevante para el caso que nos atañe, pues la llamada no deseada ha sido realizada desde un número

telefónico situado en España y ha de ser la empresa titular en España de dicho número quien deba responder por ella, ya sea Orange o Advento Networks. Posteriormente a una eventual sanción, habrán de ser ellas quienes exijan rendición de cuentas o reclamación de daños a STG Group, lo cual no es de mi incumbencia.

8. Aceptar sin más que por el hecho de situarse fuera del espacio de la UE el titular final de la línea sería tanto como decir que el RGPD es papel mojado, abonándose el terreno para que las empresas de telecomunicaciones subcontraten a terceros países fuera de la UE las gestiones comerciales de las cuales en algún momento se podrían beneficiar”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia

Es competente para resolver el presente recurso la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP) y el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo, LOPDGDD).

II

Contestación a las alegaciones presentadas

En relación con las manifestaciones efectuadas por la parte recurrente, cabe señalar que aun cuando presuntamente se tiene identificado al titular de la línea llamante, no es posible determinar quién es el responsable de la llamada al no haber contestado a los requerimientos de información solicitados por esta Agencia y, por lo tanto, no concurren aquellos presupuestos que son necesarios para la imputación de la responsabilidad a dichos sujetos.

Las investigaciones realizadas por esta Agencia indican que el número reclamado pertenece (fue cedido para su explotación a STG GROUP SAC por ADVENTO NETWORKS, S.L.), empresa ubicada en Perú.

Como ha se señalaba en la Resolución recurrida se enviaron requerimientos de información a la citada empresa y no se ha recibido respuesta a ninguno de los ellos.

Hay que señalar que la Ley General de Telecomunicaciones no confiere a la Agencia Española de Protección de Datos competencias sobre una empresa ubicada en Perú.

A través de las actuaciones realizadas por esta Agencia, no se ha podido determinar el responsable del número llamante al no haber recibido contestación al requerimiento enviado al titular final del número que es STG GROUP, con sede en Perú, no pudiendo determinarse su responsabilidad al respecto.

En definitiva, no se ha podido identificar al responsable de una presunta infracción.

Así, el artículo 28.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público señala que *“sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa”*.

En relación con lo anterior, conviene señalar que al Derecho Administrativo Sancionador, por su especialidad, le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción de inocencia.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1990, de 26 de abril, en relación con el derecho a la presunción de inocencia y del principio de culpabilidad establece: *No puede suscitar ninguna duda que la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas en general o tributarias en particular, pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.”*

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que *“Nuestra doctrina y jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales y el principio jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate.”*

En conclusión, estos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y acreditado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación o se conozca con certeza la identidad del presunto infractor, aplicando el principio “in dubio pro reo” en caso de duda.

III

Conclusión

En consecuencia, en el presente recurso de reposición, la parte recurrente no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

IV

Resolución extemporánea

Debido a razones de funcionamiento del órgano administrativo, por ende no atribuibles a la parte recurrente, hasta el día de la fecha no se ha emitido el preceptivo pronunciamiento de esta Agencia respecto al presente recurso.

De acuerdo con lo establecido en el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) el sentido del silencio administrativo en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones es desestimatorio.

Con todo, y a pesar del tiempo transcurrido, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, según dispone el art. 21.1 de la citada LPACAP.

Por tanto, procede emitir la resolución que finalice el procedimiento del recurso de reposición interpuesto.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos **RESUELVE:**

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por A.A.A. contra la resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 10 de octubre de 2022, en el expediente **EXP202201212**.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDPGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDPGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito

dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada LPACAP. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

Olga Pérez Sanjuán

La Subdirectora General de Inspección de Datos, de conformidad con el art. 48.2 LOPDGDD, por vacancia del cargo de Presidencia y Adjuntía